

条約法条約における留保の「有効性」の決定について（一）

中 野 徹 也

目 次

一、序 論

二、留保の「有効性」の決定についての二つの見解

（一） 許容性学派

（二） 対抗力学派

三、条約法条約の立場

（一） 国際法委員会での議論

（1） ウォルドック第一報告書

（2） 国際法委員会一九六二年の審議

（3） ウォルドック第四報告書

（4） 国際法委員会一九六五年の審議

（一） 外交会議での議論

（二） 小 括

（以上、本号）

四、国家及び実施機関の実行並びに国際判例

（一） 「有効性」の決定

（二） 両立しない留保の帰結

五、結 論

一、序 論

一九九四年十一月、自由権規約人權委員会は「自由権規約またはその選択議定書の批准またはそれらへの加入に際

して、もしくは同規約第四一条に基づく宣言に際して付された留保に関わる諸問題に関する「一般的意見」を採択した。⁽¹⁾ 同意見には、次のような一節が含まれていた。すなわち、

「人権関係の諸条約……は、当事国間に相互的な権利・義務関係を設定するものではなく、個人に権利を付与するものである。国家間の相互性の原則が機能する余地はない。それゆえ、この種の条約の当事国は他の当事国の留保に異議を唱えることに法的利益や必要性を見出さないことが多い。その結果、ある留保に対して抗議がなされていないことは、当該留保が条約目的と両立するか否かの判断の基準にはなりがたい。……従って、委員会は、特定の留保が規約の趣旨及び目的と両立するか否かを決定することに取り組まざるをえない。……受け入れられない (unacceptable) 留保の通常の帰結は、規約が留保国に対して完全に効力を有さなくなるという意味で、一般的に分離可能である」⁽²⁾。

もつとも、同意見によれば、条約法条約が定めている留保の定義及び許容性の基準は、国際法の一般規則であり、規約もそれに従うとされている。⁽³⁾ それゆえ、条約法条約の留保規則との関連で問題とされているのは、(1)留保の両立性を決定するさいの基準、(2)受け入れられない留保の帰結、の二点である。

人権条約に対する留保の取り扱いについて、こうした見解が示されたのは今回が初めてではない。これまでも、ヨーロッパ人権条約や米州人権条約の実施機関によりこのような見解が示され、それに沿った実行が採られてきた。⁽⁴⁾ その限りでは、今回の一般的意見は目新しいものではない。しかし、それにも関わらず、今回の意見はこれまでとは異なった意味を持ちうると思われる。

従来の地域的人権条約の実施機関の実行に対しては、その理論的根拠の脆弱性により、学説の少なからぬ批判があった。⁽⁵⁾しかし、そうした批判にも関わらず、少なくとも現在では確立した実行となっているのは、それらの実施機関が、対象とする条約の地域的特殊性をも併せて強調していたからであり、かかる実施機関の実行に好意的な評価を下す学者も、そうした地域性を前提とし、かつそれゆえに認めていたのである。⁽⁶⁾それゆえ、そうした実行を普遍的な人権条約に類推し、普遍的人権条約の実施機関又は監視機関が同様の実行を行うことには、慎重な立場を採るのが大勢であった。今回の一般的意見は、そうした大勢にも関わらず、普遍的人権条約である自由権規約について出されたという点で、注目に値する。また、その意味で、人権条約に対する留保という主題が新たな段階に入ったと見ることもできよう。⁽⁷⁾

ところで、上述の人権条約の実施機関又は監視機関がこうした実行を採るさいには、人権条約には、その特殊性性格のゆえに、条約法条約の受諾又は異議の制度が有効に機能しないので、自らが留保の許容性の判定を行うのが適当という理論構成が採られてきた。しかし、ここで一つの疑問が生ずる。実施機関又は監視機関は、仮に当該機関を設立する条約に定められた権限の問題を捨象することが許されるとしても、そもそも留保の許容性を判定できるのだろうか。換言すれば、条約の特殊性を根拠にしなければ、留保の許容性を判定しえないのだろうか。この点と密接に関係するのが、条約法条約における留保の「有効性」⁽⁸⁾(validity)の決定という問題である。

一九九五年より留保規則の再検討に着手している国際法委員会で、特別報告者のアラン・ベレは、「留保の有効性の決定こそが、一九六九年……のウィーン条約の諸規定の曖昧さが最も顕著な点であ」り、それゆえに、この点について許容性学派と対抗力学派と呼ばれる学説の対立が生じることになった、という認識を示した。⁽⁹⁾そして、ベレによ

れば、これら二つの学説を極端に押し進めれば、実際には全く対照的な結果が生まれるとされる。すなわち、「対抗力学派によれば、紛争解決機関―司法機関か否かを問わず―は、他の締約国が異議を表明しない場合、留保の許容性について判断を差し控えなければならないことになる」⁽¹⁰⁾。他方、許容性学派によれば、「条約の趣旨及び目的と両立しない又は条約により禁止されている留保に対する異議は、いかなる場合でも、当該留保は当初から無効 (null and void) なので、何ら特別の効果がないということになり」⁽¹¹⁾、それゆえ異議が提起されていないことは、許容性の判定には何ら影響を及ぼさず、許容性の判定を独自に行うことはできる（又はしなければならない）ということになるとされる。さらに、両学派は、受け入れられない留保すなわち両立しない留保の帰結についても鋭く対立している。詳細は後に譲るが、留保の「有効性」の決定という問題には、この一見無関係のように見える二つの論点が含まれているのである⁽¹²⁾。

この問題は、従来はきわめて抽象度の高い理論的な問題に留まっていたと言っても良いであろう。しかし、冒頭に引用した自由権規約人權委員会の一般的意見にも、二つの論点に関係する一節が含まれているように、その状況は変わりつつあるように思われる。

それでは、そもそも条約法条約は、その採択時に、これらの問題につきいかなる立場を採っていたのだろうか。また、条約法条約採択後の実行及び国際判例では、どちらの見解が従われているのだろうか。さらには、ペレの言うように、対立が依然として続いているとすれば、何が解決を妨げているのだろうか。

本稿は、条約法条約の起草過程及び本主題に関係する実行・国際判例に照らして、以上のような疑問を説明することを目的とするものである。それではまず両学派の見解を紹介し、対立点をより明確にすることにしよう。⁽¹³⁾

二、留保の「有効性」の決定についての二つの学派

許容性学派と対抗力学派という用語を初めて使用した論者は、筆者が知る限り、コウである。コウは、一九八二年の論文で、条約法条約の留保規則における留保の「有効性」をめぐる理論上の争いを説明するためにこの用語を使用していた。⁽¹⁴⁾そこでの説明によれば、留保の「有効性」の基準となるものには、留保の許容性 (permissibility) と留保の対抗力 (opposability) があり、⁽¹⁵⁾許容性学派は前者を「有効性」の分析にあたって第一義的かつ最も有力な側面とみなすのに対し、対抗力学派は後者を優勢な基準とみなし、前者を全く法的な重要性を有さない基準とみなす学派とされる。⁽¹⁶⁾そして、前者の立場を採る論者としてパウエットを、後者の立場を採る論者としてルダを挙げている。⁽¹⁷⁾

このように、当初は、留保の「有効性」をめぐるパウエットとルダの見解の相違を説明するという極めて限られた意図をもって、これらの用語は使用されたのであった。⁽¹⁸⁾これらの用語は、その後十数年間忘れられた存在であったが、一九九三年、レッジウェル (Redwell) がイギリス国際法年鑑に掲載された論文の中で言及し、⁽¹⁹⁾さらには前述したように、ペレの報告書でも言及され、一躍注目されるようになった。それはともかく、これらの用語がパウエット対ルダの論争を説明するために提示された以上、まず、二人の見解を見なければならぬ。

それではまず、パウエットの見解を見てみることにしよう。

(一) 許容性学派

パウエットは、条約法条約の留保規則を解釈するにあたって、許容される留保と許容されない留保を区別すること

から出発する。この区別は、当事国の意思（第一九条に規定されている三つの選択肢のうちのどれを選択したかという意思）から導かれ、従って、ある留保が許容されるか否かの究極的な基準は、条約自体に規定されていると言う。⁽²⁰⁾さらに、当事国は、この決定を行う際に、単に政策上の問題として、ある留保を許容されないとみなし、受諾を拒む権利を有さない。仮に、そのようなことをすれば、当事国の、留保に反対しかつそれゆえに自国に対して当該留保を對抗できないものにするという疑いのない権利と、留保が許容されるか否かという全く別個のかつ優先的な問題とが混同されることになる。また許容性の問題は、条約自体により規律されるので、法律問題であり、従って司法的決定に適したものである。⁽²²⁾

では、許容性の決定を行った後に、当事国にはいかなる対応が開かれているのだろうか。この点につき、パウエツトは、許容される留保については、条約法条約第二〇条の規定が適用されるとする。その際、当事国が異議を申し立てる場合であっても、当該異議に何らかの法的根拠が必要とされるわけではない。なぜなら、当事国は、純粹に政策的な理由で異議を申し立てる権利を有しているからである。⁽²³⁾これに対して、許容されない留保に対しては、当事国には、当該留保を受諾するという道は開かれていない。第一九条(a)項及び(b)項に該当するという理由で、許容されないと認定した留保を受諾するという行為は、合意された留保条項に反することになるので、条約の違反となる。また、(c)項に該当する許容されない留保の場合には、条約を受諾するという当事国の行為と当該条約の趣旨及び目的に反すると認定している留保を受諾するという当事国の行為には、明らかに矛盾があるからである。⁽²⁴⁾

こうした過程を経た留保は、いかなる帰結を生ずるのだろうか。パウエツトによれば、許容される留保については、条約法条約第二一条に規定されている帰結が生ずるとされる。⁽²⁵⁾しかし、許容されない留保には、許容される留保だけ

を想定している第二一条は適用されないので、別個の理論構成が必要になる。そこでこの点につき、バウエットは、条約により拘束されることについての意思表示と、その意思と矛盾する条件を留保という形式で課すという意思表示のどちらが優先されるべきであるかという問題提起をしたうえで、原則として、前者の意思が優先すると結論する。さらに、この結論を直接裏付けるような権威 (authority) はないとし、安易な類推には慎重な態度を採りつつも、インターハンデル事件でのローターパクト判事等の意見に依拠し、二つの帰結を導いている。すなわち、(1) 留保のみが無効 (留保の可分性)、(2) 条約への参加すなわち批准又は加入そのものが無効、という帰結である。前者は、国家の第一義的な意思が、条約を受諾することであり、かつ当該留保が条約の趣旨及び目的に根本的に反していない場合、後者は、留保と条約の受諾が密接不可分の関係にあり、かつ当該留保が条約の趣旨及び目的に根本的に反している場合とする⁽²⁶⁾。

以上の見解をまとめて、バウエットは次のように述べている。重複する部分もあるが、最も頻繁に引用される箇所でもあるので、あえて引用してみたい。

「許容性 (permissibility) の問題は、先決的な問題である。それは条約に照らし合わせて解決されなければならないものであり、本質的には条約解釈の問題である。政策の問題として、他の当事国が当該留保を受諾可能とみなすか、もしくは受諾可能でないとみなすか、という問題とは何の関係もない。留保を許容されないと認定した場合の帰結は、留保だけが無効……となるか、国家による条約全体の受諾が無効となるかのいずれかである。

対抗力 (opposability) の問題は二次的な問題であり、留保が許容されるということを前提としている。当事国が、留保を受諾する又は異議を提起するもしくは留保国と異議国との間の条約の効力発生に反対する、それら

のいずれを選択するかは政策決定の問題であり、……許容性を規律する基準及び司法判断には服さないのである⁽²⁷⁾」。

この箇所に見られる許容性と対抗力の区別、これこそが留保の「有効性」をめぐる見解の対立を分析する出発点であり、また、許容性学派と対抗力学派という名称の由来でもあるが、ここでひとまずパウエットの見解を、筆者なりに整理しておきたい。この見解を理解するために最も重要と思われる点は、パウエットが、第十九条による留保の許容性の決定という問題と、第二〇条における受諾又は異議という対抗力の問題とを、全く切り離して議論を進めていることである。つまり、他の当事国は、まず留保の許容性を決定しなければならないが、それは、第二〇条における受諾又は異議によってではなく、全く別個にかつ先決的に、条約解釈の問題としてそうしなければならないのである。そして、許容される留保であれば第二〇条に従い、受諾又は異議のいずれかを選択することができ、さらに、許容される留保だけが第二一条に規定されている帰結を生ずるのである。このようにならないのは、許容性の問題と対抗力の問題は、「全く別の問題であって順序立てて検討されなければならない」からである⁽²⁸⁾。

ところで、パウエットは、この分析にあたって「有効性」という表現を使っていない。それは、この表現は「二つの異なった問題、……留保の許容性と留保の対抗力とを混同している」と考えたからだとされる⁽³⁰⁾。

さて、この見解を支持する論者も若干いるものの⁽³¹⁾、大方の支持を得るまでには至っていない。大勢を占めるのは、コウが対抗力学派と名づけた見解であるとされる。それでは、対抗力学派とはどのような見解で、許容性学派とはどこが異なるのだろうか。

(二) 対抗力学派

対抗力学派に属すると言われる論者は、許容性学派とは異なり多数存在する。⁽³²⁾しかし、本章の初めに述べたように、元々この論争は、パウエットとルダの見解の相違から始まっているので、まずルダの見解を概観することにした。

ルダは、条約法条約における留保の「有効性」について、次のように言う。

「この制度の下では、留保の有効性は、もっぱら他の締約国が留保を受諾するか否かにかかっている。もちろん、条約の趣旨及び目的と抵触する留保を受諾することに、国家は何らの利益をも有しないと推定されるが、かかる考慮は、例えば政治的動機により覆されうる。たとえ、ある留保が条約の趣旨及び目的に本質的に反する場合でも、国家が当該留保を受諾することを妥当とみなすさいには、そうすることを妨げるものは何もないのである。留保は条約の趣旨及び目的と両立していないものであってはならない」という指摘(indication) またはかかる指摘の欠如は、最終的には、各国が独自にその事柄を決定するのであれば、実際上は法的な重要性をもたない。留保の有効性は、(条約法「筆者注」) 条約の制度の下では、条約の趣旨及び目的との両立性に基づき、その許容性条件が満たされているか否かということではなくて、当該留保が他国によって受諾されるか否かにかかっている。このような単純な結論から、第一九条(c)項は、国にとって留保を受諾するか否かを決定する際の指針(guideline) にはなりうるが、それ以上のものではない、とみなすのが正しい⁽³³⁾」。

このように、ルダは第一九条(c)項が適用される条約に対する留保をもっぱら問題とし、その点について、パウエットとは正反対の結論を導いている。それでは、ルダはなぜこのような結論に至ったのだろうか。

まず、ルダも第一九条が「条約に記された全制度の出発点である」とし、⁽³⁴⁾パウエットと同様に、同条の重要性を指

摘する。しかし、第二〇条についての認識、より正確に言えば、第一九条(c)項と第二〇条四項との対応関係についての認識は全く異なる。すなわち、「第一九条は、すべての国の留保を付す権利を承認しているが、他国はかかる留保を受諾又は拒否する権利をもつ。それゆえ、第二〇条の根底にある主たる観念は、同意が留保の有効性の基礎であるということになる」⁽³⁵⁾という前提から出発し、その帰結として、他国は、第一九条(c)項に定められた留保の許容性条件が満たされているか否かを、第二〇条四項に従って判定するのであるとする⁽³⁶⁾。しかし、第二〇条四項での判定は、各国の受諾又は異議により個別になされることになっている。それゆえ、結果的には、受諾と両立性は同義ということになる。もちろん、他国は両立しない留保を受諾しないと推定されうが、仮に両立しないと考えていたとしても、受諾されてしまえばそれを立証する手段がない。その結果、理論的には、留保の「有効性」は留保の許容性と対抗力という二つの基準により決定されるのであるが、実際には、各国の受諾又は異議により示される対抗力の有無により⁽³⁷⁾許容性が判定されることになるので、留保の「有効性」は対抗力の有無如何にかかっているということになる。

以上、留保の「有効性」をめぐる見解の相違を、許容性学派と対抗力学派に分類して説明する契機となった二人の論者の見解を見てきた。繰り返しになるが、彼らが対立する点を今一度確認しておこう。まず、バウエットによれば、許容性は条約解釈の問題であり、先決的に決定されなければならないとされる。そして、許容される留保は、当然に「有効」である。当該留保が他の締約国に対して対抗できるか否かという問題は、許容性には何の影響も与えないのであり、たとえ異議が提起され対抗できなくなったとしても、許容される留保であることに変わりはなく、依然として「有効」な留保なのである。それゆえ、留保の「有効性」とは、まさに許容性であり、「有効性」という言葉を使うことは、対抗力という全く別個の問題を混同しているかのような印象を与えるので望ましくないと、言う。他方、

ルダは、第一九条(a)項及び(b)項が適用される条約に対する留保については、パウエットとはほぼ同じ考えをもっていると思われるが、第一九条(c)項が適用される条約に対する留保については、異なる見解を提示した。すなわち、その場合には、「同意が留保の有効性の基礎」であるという認識に基づき、留保の許容性すなわち両立性は、パウエットが単なる政策上の問題とみなした他の締約国の受諾又は異議(第二〇条四項)により決定されるとする。換言すれば、許容性と対抗力は同一歩調をとる (go hand in hand) のである。⁽³⁹⁾ このように、彼らが対立する点は、他の締約国の受諾又は異議が留保の許容性に及ぼす効果、条約法条約の規定に即して言えば、第二〇条、特に四項の意味であった。両学派の元々の対立点は、以上のような点にあった。しかし、ルダ以降の論者で対抗力学派に分類されている者は、皆ルダと同一というわけではない。確かに、ほとんどルダと同一の見解を示す論者もいるが、⁽⁴⁰⁾ ルダとは異なる観点から、あるいはルダの見解を発展させて独自の理論を示す論者もいるのである。

まず、アンベールの見解を見てみよう。アンベールは、「第二〇条四項において、留保の受諾は、個別的に決定される。……この決定が、第一九条(c)項に規定された両立性の基準の枠内においてのみ下されうとは、明記されていない」と言う。⁽⁴¹⁾ そして、条約法条約の起草過程を検討した上で、「第一九条と第二〇条との間に絶対的な紐帯が欠如しているので、結局は留保の受諾は許容性条件とは無関係に行われる」と結論している。⁽⁴²⁾

この見解は、結論的にはルダと同じであるが、ルダとは異なり、第一九条四項と第二〇条四項との間に、明示の対応関係がないことを重視している。その点は、逆に許容性学派と同じであるが、正反対の結論になっているのが興味深い。

ここまでの二人は、ニュアンスの違いはあるものの、いずれも第一九条(c)項と第二〇条四項との関係を問題にして

いた。ところが次に見る二人は、彼らとは異なる点にも着目し、非常に興味深い見解を提示している。

ツエマネックは、まず第一九条に即して許容される留保と許容されない留保を区別することから出発し、第一九条(a)項及び(b)項に反する留保は、条約規定の明確な違反であると言う⁽⁴³⁾。しかし、(c)項に違反する留保の場合、他の締約国は、当該留保は条約の趣旨及び目的と両立しないという異議を申し立てることができるが、その時、第二〇条四項(b)によれば、異議国には、自国と留保国との条約関係の発生を妨げるか否か、という二つの選択肢がある。前者の場合には、条約関係が存在しないので問題は生じない。後者の場合は、本来、非両立性を理由として留保に対し異議を申し立てる国は、原則として、自国と留保国との間に条約関係が発生することを認めるべきではないので、純粹な空論(speculation)に留まるべきである。しかし、仮に、後者が選択された場合、第二一条三項が適用されることにならざるをえないが、当該条項は、許容される留保と許容されない留保とを区別していない。それゆえ、当該留保は法的な意味では「効力を生じ」(take effect)ないはずであるが、実際にはあたかも効力を生じているかの如く取り扱われるのであり、条約規定は、留保に係る規定を除いて、留保が条約の趣旨及び目的と両立しているか否かに関係なく、異議国と留保国との間において適用されるのである、と言う⁽⁴⁴⁾。

この見解は、両立性の判定が第二〇条四項により行われること、すなわち、留保の「有効性」は、対抗力の有無により決定されることを認めるという点では、ルダと同様である。しかしながら、ツエマネックは、ルダやアンペールのように、結局は留保の「有効性」の決定が許容性とは無関係に行われることになるということを、第二〇条四項との関係で言っているのではない。彼は、ルダのように政治的動機などは問題にしていない。第二〇条四項の段階では、両立する留保と両立しない留保を区別できることは認める。問題は、そこでの区別が第二一条三項に反映されていない

いことにあり、その結果、結局は留保の「有効性」は許容性とは無関係に決定されることになると言っているのである。

最後に、ガヤの見解を見ておきたい。ガヤは、明示的に又は黙示的に特定の留保を禁止している条約に付された留保が、許容されないと認定された場合には、かかる留保を付した国は条約の当事国になることを妨げられる、と言う。しかし、「許容されない留保の第三の範疇に関しては、ウィーン条約の規定をこのように読む者は、ほとんどいない」と指摘する。⁽⁴⁵⁾すなわち、この第三の範疇の留保（条約の趣旨及び目的と両立しない留保）には、許容される留保に適用される留保の受諾又はそれに対する異議と同一の制度が適用されるという見解が優勢であり、⁽⁴⁶⁾さらにこの見解が「ウィーン条約を正確に解釈しているか否かはさておき、実際、許容される留保と許容されない留保の区別は、……不鮮明になっている」と指摘する。⁽⁴⁷⁾そして、国家実行を綿密に検討した結果、「諸国家は、許容される留保を付すことができるのと同様に、『条約の趣旨及び目的と両立しない』留保を自由に付すことができる」とし、⁽⁴⁸⁾さらに両立しない留保を禁止する規則が、一般国際法上存在すると考えることはできないと述べている。ガヤがこうした結論に至る根拠は、概ね、ツェマネックと同様であるが、⁽⁵⁰⁾さらに進んで両立しない留保を自由に付すことができるとまで述べている。

このように、対抗力学派としてひとまとめに括られているものの、実際には、彼らの理論構成が一樣でないことがわかる。ルダは、両立性の判定が、個別国家による受諾又は異議により行われるという前提から出発する。そして、その判定が恣意的になされる可能性を強調することによって、両立性という許容性の基準を「単なる理論上の主張」と位置付けた。アンベールは、許容性学派と同様に第一九条(c)と第二〇条四項との間に対応関係がないとしつつも、

ルダと同様の結論に至った。他方、ツエマネックやガヤは、出発点はルダと同じである。しかし、彼らは、両立性の判定の恣意性を声高に叫んだりはしない。彼らは、第二〇条四項により、両立する留保と両立しない留保を区別することは可能なのであるが、その区別の基準となるはずの異議の帰結が、条約法条約の規定上（すなわち第二二条三項）、留保の許容性如何で差違のあるものにはなっていないことに注目する。彼らは、許容性学派のような理論構成に賛同せず、それがあるがままに読む。そして、留保の「有効性」は許容性を満たしているか否かに関係なく決定されることになる、又は実際にそうなっている、と結論するのである。つまり、彼らは、許容性学派の見解を、第十九条(c)と第二〇条四項との対応関係と、両立しない留保への第二二条三項の適用性という二つの点から否定しているのである。こうしてみると、対抗力学派として、ひとまとめに分類することが、果たして妥当かという疑問も生じてくる。しかしながら、いずれにしても、対立点は明確になっていると思われるので、本稿では、その点には深く立ち入らないことにする。

以上、両学派の見解を、かなり詳細に見てきたが、本章の最後、二つのことを確認しておきたい。まず、立場の如何を問わず、第十九条(a)項と(b)項の範疇に入る留保の「有効性」の決定については、両学派間での争点にはなっていない⁽⁵⁾。両学派間の争点となっているのは、第十九条(c)が適用される条約に対する留保の「有効性」の決定と両立しない留保の帰結である。換言すれば、(1)留保の許容性は何を基準に判定されるのかという問題と、(2)両立しない留保にも第二二条三項が適用されるのか、という問題である。

それでは、そもそも条約法条約は、これらの問題につきどのような立場をとっていたのだろうか。起草過程を辿ってみることにしよう。

三、条約法条約の立場

周知のように、条約法条約での現行留保規則の直接の基礎となったのは、ウォルドック草案である。また、前章で紹介したように、両学派の対立は、基本的には、現行留保規則の解釈をめぐる生じている。それゆえ、本稿での目的上、ウォルドック草案以前の議論にまで遡る必要はないと思われるので、同草案以降に対象を限定し、考察を進めていきたい。⁽⁵²⁾

(一) 国際法委員会での議論

(1) ウォルドック第一報告書

ウォルドックは、一九六二年に第一報告書を提出したが、その留保に関する規定は、非常に詳細かつ複雑なものであった。それらのうち、本稿との関連では、第一七条及び第一八条一項並びに第一九条四項の各規定が重要である。それぞれ、次のように規定されていた。

「第一七条（留保を表明する及び撤回する権能）

1.

(a) いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、条約への加入若しくは条約の受諾に際し、留保を付することができる。

i 留保の表明が、条約の文言により禁止されている場合、若しくは条約の性質により又は国際組織の確立

した慣行により排除されている場合

ii 条約が明示的に、留保の表明を特定の範疇又は複数の特定の範疇の留保に限定している場合で、当該留保が条約に述べられた範疇又は複数の範疇に該当しない場合

iii 条約が明示的に、特定の範疇又は複数の特定の範疇の留保の表明を認めている場合で、認められた範疇又は複数の範疇に該当しない留保の表明が黙示的に排除されている場合

(b) (a) 項のいずれかの規定により、明示的に禁止されている若しくは黙示的に排除されている留保の表明は許容されない。ただし、他のすべての利害関係国の事前の同意が最初に得られている場合は、この限りでない。

2.

(a) 本条の1項(a)の規定に基づき、いずれの国も、留保を付す際には、当該留保と条約の趣旨及び目的との両立性を考慮しなければならない。

(b) 留保の表明が留保を付した国と条約を署名、条約を批准、条約へ加入若しくは条約を受諾する他の国若しくは諸国との間の法的関係に及ぼす効果は、第一八条及び第一九条以下の規定により決定されなければならない。

「第一八条（留保に対する同意及び同意の効果）

1. 留保は、採択された条約の文言の修正を意図するもので、本条の以下の項の規定に従って、留保に対する同意を与えた若しくは与えたと推定される国に対してのみ有効でなければならない。」

「第一九条（留保に対する異議及び異議の効果）

条約法条約における留保の「有効性」の決定について（一）

4.

(c) 多数国間条約の場合には、異議は、異議を申し立てる国と留保を付した国との間における条約の効力発生を妨げるが、留保を付した国と留保に異議を申し立てていない他の国との間の条約の効力発生が妨げられることはない⁽⁵³⁾。

これらの規定について、ウォルドックは次のように説明している。第一七条一項では、条約自体が留保の表明を禁止又は制限していない場合には、いずれの国も、妥当と考える留保を自由に表明することができる、ということが規定されている。⁽⁵⁴⁾ しかしながら、その場合には、当該留保の有効性は、他の利害関係国の対応如何による。なぜなら、留保国の同意表示行為（批准又は加入等）には、未だ他の関係国が同意していない事柄が含まれているのであり、他の関係国には、そのような同意表示行為を、自国に対して有効なものとして取り扱う義務はないからである。⁽⁵⁵⁾ このことが、第一八条一項で明示的に規定されていたのであるが、この見解こそが、彼の条文草案の出発点であり、非常に重要な点と思われる。すなわちこの見解に基づき、留保について沈黙している条約について、一方では、留保を「提案する」権利を規定しつつ、他方、その「有効性」はあくまで合意の問題であるとし、それにより留保国に留保を「付す」という絶対的な権利を認めず、逆に、他の締約国には絶対的な異議申立権を認めていたのである。換言すれば、留保国と異議国は、対等の立場ではなかったのである。⁽⁵⁶⁾

他方、条約が明示的に又は黙示的に禁止している留保と明示的に認められている留保の帰結は、他国の対応に関係なく決定される。なぜなら、条約により留保が禁止されている場合には、他の諸国は、既に当該条約の中で異議を表明しているのであり、逆に認められている場合には、受諾を表明しているからである。⁽⁵⁷⁾

ところで、この六二年草案と現行規定との大きな相違は、両立性の基準の位置付けにある。現行第十九条では、三つの許容性の基準の一つとして、他の二つと同列に規定されているが、六二年草案では、第二項(a)として別個に規定されているだけでなく、後続する条文との関係についても何も規定されていなかった。この点について、ウォルドックは、両立性の基準を挿入することには「若干のためらい」を感じたことを告白しつつ、次のように述べている。両立性の基準は「本質的に主観的なものであり、留保国が多数国間条約の当事国とみなされるか……否かを決定するための一般的な基準として用いるには不適当であり」、第十九条及び第十九条では、……各国の同意又は当該特定の留保に対する異議という純粋に客観的な基準に基づき機能する柔軟な米州制度を採用すべきである」と。(59) それにも関わらず、この規定を挿入したのは、両立性の基準が「留保を表明する諸国と、他国が表明した留保に同意するか否かを決定する諸国の双方により、考慮されるに値する概念」(60) だからである。しかしながら、両立性の基準と他の諸国による留保の受諾又は拒否という客観的基準とを組み合わせ、留保国の当事国としての地位を決定する際にはいくつかの困難があると感じられ、従って、第一八条及び第一九条においては、両立性の基準を採用しなかった、とされる(62) (傍点筆者)。

ウォルドックの両立性の基準についてのこのような見解は、非常に興味深い。少なくとも、この段階では、両立性の基準は、実質的には単なる指針 (guideline) にすぎないものと、ウォルドックは考えていたように思われる。(63) つまり、他の締約国の受諾又は異議という「客観的基準」のみが、留保の「有効性」を決定する基準なのであり、それ以外の許容性の基準は存在しなかったのである。(64) 従って、この段階で、ウォルドックが、留保について沈黙している条約の場合に適用される制度として提示したのは、汎米慣行制度であり、それは「純粋に合意に基づく制度」であった

と言えるだろう。⁽⁶⁵⁾ また、上述のウォルドックの説明にもあるように、留保の「有効性」と留保国の当事国性が不可分の関係と考えられていたことも興味深い。すなわち、異議は留保の「有効性」を否定し、例外なく異議国と留保国との間における条約の効力発生を妨げるという効果を有していたのである(第一九条四項(c)参照)。

それでは、以上のようなウォルドックの六二年草案について、国際法委員会ではどのような議論が展開されたのだろうか。

(2) 国際法委員会一九六二年の審議

国際法委員会は、一九六二年の第一四会期で、上記のウォルドック草案を審議した。多数国間条約について全会一致の原則を放棄し、⁽⁶⁶⁾ また両立性の基準を指針として採用するという、過去三人の特別報告者及び従来の国際法委員会の立場とは異なる姿勢を打ち出したウォルドック草案に対し、ウォルドック本人の希望もあり、まずはいくつかの原則上の問題、⁽⁶⁷⁾ すなわち委員会が「留保についていかなる基本的態度をもつて臨むべきであるか」⁽⁶⁸⁾ という問題についての一般的審議が行われた。この一般的審議は、その後の委員会の留保に対する基本姿勢を決定づけたものとして重要であるが、これについては既に我が国にも詳細な研究がある。⁽⁶⁹⁾ それゆえ、ここでは、本稿の目的と関連する点、特に、ウォルドックが、留保について沈黙している条約に適用されるべきであると考えた制度が、委員会ではどのように受けとめられ、また審議されたかという点に重点を置いて、委員会での審議を見て行くことにしたい。

さて、当初委員会では、ロゼンヌのように「三ヶ条すべてに両立性の基準を拡大するほうが賢明」と述べて、⁽⁷⁰⁾ ウォルドック草案の修正を求める委員もいたが、ウォルドック案に同意する委員のほうが多かった。⁽⁷¹⁾ そうした状況の中で、ウォルドックもロゼンヌの意見に対して「国が留保に対し異議を申し立てた場合、異議を申し立てた国は、留保を付

した国との関係では、条約の当事国にならないというのが……一般的な法であり、両立性の問題とは関係なく、その点を維持することは正しいと考える」(傍点筆者)と答えるなど、あくまで留保の「有効性」の決定に、主観的な許容性の基準は取り入れないという姿勢を崩さなかった。⁽⁷²⁾

しかし、審議が進むにつれて、次第にウォルドックの見解には支持が集まらなくなっていった。国際司法裁判所が、ジェノサイド条約に限定して述べた両立性の基準を、多くの委員は、留保に関して沈黙している多数国間条約一般において、留保の許容性を決定する基準とみなすようになっていったのである。⁽⁷³⁾

こうした状況を受けて、委員会は、一般的多数国間条約が、留保に関して明示又は黙示の示唆を含んでいない場合、(1)いずれの国も、条約の趣旨及び目的と両立する留保を自由に付すことができ、(2)条約へ参加する他の国は、条約の趣旨及び目的と両立しているとみなさない留保に対し異議を申し立てることができる、という二点を出発点とすることに合意し、ウォルドック草案は起草委員会に送られることになった。そして、起草委員会が新たに作成した条文では、両立性の基準が第一七条一項(d)に挿入されていた。すなわち、

「第一七条(留保の表明)

1. いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、条約への加入若しくは条約の受諾に際し、留保を付することができる。

……

- (d) 条約が留保の表明に関して沈黙している場合には、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しない場合⁽⁷⁵⁾。

ここで初めて両立性の基準が、条約が沈黙している場合に、留保の表明を規律する許容性の基準として置かれるこ

とになった。しかし、なお第一七条以下の規定では、両立性の基準は挿入されていなかった。その点につき、ウォルドックは、留保の非両立性以外の理由でも異議を申し立てることができるために、あえて両立性の基準には言及しなかった、と述べている。⁽⁷⁶⁾ 従って、第一八条以下の規定で、両立性の基準が挿入されなかったことから、留保の両立性を無視して、受諾又は異議を選択できるということになるわけではなく、その真の意図は、異議を申し立てる権利を制限すべきではないということだったのである。⁽⁷⁷⁾ しかしながら、皮肉なことに、この考慮が、「留保の有効性」を規定していた起草委員会草案第一八条⁽⁷⁸⁾一項(b)との関連で、激しい議論を引き起こす原因になってしまった。第一八条⁽⁷⁹⁾一項(b)は、次のように規定されていた。

「第一八条⁽⁸⁰⁾ (留保の有効性)

1.

(b) 第一七条(d)項の場合には、留保の有効性は、本条の二項から四項までの規定に従うことを条件として、当該留保の受諾如何による⁽⁸¹⁾」。

ちなみに、第二項は、次のように規定されていた。

「

2.

(a) 条約の当事国になることを承諾している国が留保を受諾することにより、当該受諾国と留保を付した国との間においては、当該留保の有効性が確立され、……条約の当事国関係に入る。

(b) 留保に対していずれかの国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該異議を申し立てた国との

間における条約の効力発生は妨げられる。ただし、当該異議を申し立てた国が別段の意図を表明する場合は、この限りでない⁽⁷⁹⁾。

この規定に対しては、両立性の基準が特に言及されなかった上述のような理由を評価し「両立性の基準は、起草委員会が今提案した全制度に固有のもので、両立性の基準への言及は、……不必要である⁽⁸⁰⁾」と肯定的な評価を与える委員もいた。しかし同時に、「第一八条第(一)項(b)は、条約の趣旨及び目的と両立しない留保でさえ、他の国により受諾されれば、その結果有効になりうることを規定している」との指摘⁽⁸¹⁾に見られるように、第一七条(一)項(d)との矛盾を危惧する委員もいた⁽⁸²⁾。アゴーもその一人であり、彼は次のような修正案を提示するにまで至った。

「条約が留保の表明に関する明示的な規定を含んでいない場合には、条約の趣旨及び目的と両立する留保の有効性は、本条の二項から四項までの規定に従うことを条件として、留保の受諾如何による⁽⁸³⁾」。

この修正案からは、両立する留保の「有効性」は、受諾如何によるが、両立しない留保は、そもそも無効であり、たとえ受諾されても無効な留保が有効になるわけではない、という觀念が窺われる。これは、両立性の基準を許容性の基準として採用することを決定した以上、一見疑う余地のない正当性を有しているように見える。しかしながら、この修正案に対し、トゥンキンは、次のような疑いを投げかけた。

「条約が留保という主題に関して沈黙している場合に、条約の趣旨及び目的と両立する留保の有効性が、留保の受諾如何によると述べることは、幾分矛盾しているように思われる。おそらく受諾しないということ自体が、留保と条約の趣旨及び目的との両立性如何によることなのであり、実際には、留保と条約の趣旨及び目的との非両立性が、異議の唯一の理由になるであろう。しかし、アゴーの修正案は、両立性の基準がまず適用されるべきで

あり、受諾の問題は、留保がその基準を満たした後に生ずるということを暗に意味している。実際には、国が留保を受諾又は受諾しないということは、留保が両立性の基準を満たしているか否かに関する国の見解により決定される⁽⁸⁴⁾。

要するに、トゥンキンは、留保の両立性が決定される時期と方法を問題にしたのである。アゴーの修正案では、両立する留保の「有効性」のみが、他国の受諾如何に関わるとされ、あたかも留保の両立性が事前に決定されるかのようであるが、実際には、両立性を事前にかつ統一的に判定する機関が存在しない限り、他国の受諾又は異議を基準にして、両立性を決定せざるをえない。それゆえ、アゴーの修正案は矛盾している、と考えたのである。しかしこの批判に対して、アゴーは次のように反論した。

「留保に関して、唯一残っているセーフガードは、条約が沈黙している場合には、留保は条約の趣旨及び目的と両立しないものであってはならないということである。その条項が客観的な価値を有するのであれば、留保の有効性は、もっぱらすべての関係国による受諾如何によるわけではないことになるが、そうでなければ、全く価値のないものになる。トゥンキン……は、実質的には、留保の有効性は、条約の趣旨及び目的と両立しているか否かに関係なく、国家による受諾如何によると言っている。そのようなテーゼは、第一七条一項の規定を完全に無に帰するもの⁽⁸⁵⁾」であり、「留保の表明を規律する原則と留保の受諾を規律する原則という二つの異なる原則が存在することなどありえない⁽⁸⁶⁾」。

これに対してトゥンキンは、

「国際法の原則はすべて客観的であり、両立性の基準も客観的な原則の一つである。他方、特定の留保が条約の

趣旨及び目的と両立しているか否かに関して、見解が異なる可能性がある。かかる見解の相違は、主権国家上位する権威が存在しないために、国際法上頻繁に生じるが、それは規則自体が客観的でないことを意味するものではない⁽⁸⁷⁾」

と、再度アゴーを批判したが、両立性の基準が、第一八条 bis に反映されるべきであることには同意し⁽⁸⁸⁾、やや歩み寄る姿勢を見せた。

この両者の議論は、留保の許容性の基準として、両立性の基準を採用したことの産物であるように思われる。それにより、留保の「有効性」の決定に、対抗力の有無だけでなく許容性が関係することになり、さらに、許容性をいかに判定するかという問題が出現することになった。確かに、両立しない留保は表明できないということを出発点とした以上、両立しない留保が受諾され、その結果有効になるということなど、本来あってはならない。アゴーの修正案は、その点を明確にしようとしたものであったことが、トゥンキンとの議論からは窺える。その觀念自体は正しい。しかし、やはりトゥンキンが言うように、両立性の判定を事前に行う機関又は制度が存在しない場合には、両立性をいついかにして判定するかという問題に突き当たってしまうように思われる。既に、委員会は、そうした機関又は制度を樹立せず、個別国家による判定という汎米慣行形式を採用することを決定していた以上⁽⁸⁹⁾、この点に関しては、トゥンキンの批判にやや分があるように思われる。また、アゴーの「トゥンキンは、留保の有効性は、条約の趣旨及び目的と両立しているか否かに関係なく、国家による受諾如何によると言っている」という批判も、やや的外れのようと思われる。トゥンキンは、国家が、ある留保を受諾するか否かは、当該留保の両立性如何によると言っているであり、両立性を無視して、いかなる対応をも採ることができると言っているのではないからである。

いづれにせよ、委員会は、両立性の基準を許容性の基準として挿入したことにより、ウォルドックの原案では起りえなかった問題に取り組まざるをえなくなった。そしてその点との関係で、激しい議論の対象となった第一八条の第一項(b)であったが、結局、当該条文は、起草委員会へ差し戻されることになった。起草委員会により修正された条文は、次のようになった。

「第一八条bis (留保の効果)」

1.

(b) 条約が留保の表明に関して沈黙している場合、本条の二項から四項までの規定が適用されなければならない。

2.

(a) 留保を付した国は、条約の当事国になることが開放されている国で、かつ留保を受諾する国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときは、その受諾の時に、条約の当事国関係に入る。

(b) 留保に対し当該留保を条約の趣旨及び目的と両立しないとみなした国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生は妨げられる。ただし、当該他の締約国が、別段の意図を表明する場合は、この限りでない⁽⁹⁰⁾。

ここに至って、ついにウォルドックが絶対的と考えていた異議を申し立てる権利が、両立性の基準により制限されることになった。この変更は、これまでの委員会の議論に照らして見れば、タウンキンや初期のロゼンヌの主張を採り

入れた結果と思われる⁽⁹¹⁾。しかしながら、アゴアの主張が全く無視されたわけではなく、異議の場合に、両立性の基準をリンクさせることによって、両立しない留保も受諾され、その結果有効になりうるという可能性を排除しようとしているように思われる。いずれにしても、ウォルドックの異議の性質に関する一貫した主張は、両立性の基準を留保の許容性の基準として採用したことに伴い、この段階では変更を余儀なくされたのであり、その意味では重大な変更点であった⁽⁹²⁾⁽⁹³⁾。もともと、ウォルドックは、この変更完全に納得したわけではなかった。そのことが、後に明らかになる。

ところで、第一八条 bis 二項(b)には、最初の起草委員会草案から、「ただし、当該他の締約国が、別段の意図を表明する場合は、この限りでない」という但書きが挿入され、委員会仮草案でも維持されることになった。これは、異議国が、留保国との間における条約の効力発生を妨げるか否かを選択できるようにすべきである、との意見が初期の段階で複数の委員から出されたためであろう⁽⁹⁴⁾。こうした意見の趣旨は、異議国の意思を尊重すべきであるというもので、それにはそれなりの根拠がある。しかし、結果的には、この但書きが、両立性の基準の法的価値を脅かしうる元凶になってしまったように思われる。つまり、起草委員会が修正した条文に即して言えば、異議は留保の非両立性を意味することになる。しかし、異議国が別段の意図を表明した場合、当該留保はいかなる帰結を生ずるのか、そのことについて、後続の条文は何も規定していないのである。従って、結局のところ、留保の両立性は実質的な差違をもたらさない、ということになる余地が残されてしまったように思われる。両立性の基準が許容性の基準として採用されていなければ、さほどの問題はなかっただろう。実際、この修正を求めた意見は、まだ両立性の基準が許容性の基準として採用されていなかった初期の段階で出されていた。上述したように、その後両立性の基準の位置付けは変更

されたのであるが、委員会での議論は、これも上述したように、当該基準の客観性確保という点に集中してしまい、この点にまでは及ばなかった。

さて、国際法委員会の一九六二年の審議はここまでである。上記のような審議を経て採択された条文は、第十七条は第一条に、第一条は第一条に、第一条 *provis* は第二〇条として委員会仮草案となり、各国政府に送付された。

(3) ウォルドック第四報告書

第四報告書は、各国政府のコメントを参照して、一九六五年に提出された。各国政府から寄せられたコメントには、いくつか興味深い内容のものが含まれていた。

まず、両立性の基準と第一条及び第二〇条との関係について、日本・イギリス等がコメントしている。まず、日本は「条約の趣旨及び目的と両立しない留保は当初から無効とみなしているように見える第一条一項(d)と、両立性を規定した条文の適用を個別当事国の裁量に委ねているように見える第二〇条二項(b)とは矛盾⁽⁹⁵⁾」していると指摘していた。次に、イギリスは、「一般的に、条約の趣旨及び目的と両立しない留保を、第一条の下で、受諾することが可能であってはならず、第一条と第二〇条の規定は、その解釈・適用が国際裁判に従ってなされるのであれば、受け入れることがより容易になる」と考えた⁽⁹⁶⁾。また、デンマークは、「両立性の基準自体に反対し、さらに「第一条は、許容されない留保を含めて、いずれの留保にも適用されるという印象を与えうるが、留保が条約により明示的に又は黙示的に禁止されている場合、他の当事国は当該留保を受諾しえないし、当該留保が有効になることを妨げるために、留保に反対するよう要求されることもない」とコメントしていた⁽⁹⁷⁾。

次に、第二〇条二項(b)について、カナダは、異議の理由は留保の非両立性に限定されることを、より明確にすべき

であるとコメントしたが、オーストラリア・デンマーク・アメリカは、そのように限定されるべきではないとコメントしていた。⁽⁹⁸⁾

さて、こうした各国政府のコメントを受けて、ウォルドックは代替草案を作成した。これは、デンマーク政府の「第十九条は、許容されない留保を含めて、いずれの留保にも適用される」というコメントに留意してのことであるとされる。⁽⁹⁹⁾ それゆえ、その点を明確にするために、留保を認めている又は禁止している条約（第十八条）と留保に關して沈黙している条約（第十九条）が、別個に規定された。まず第十八条は次のように規定されていた。

「第十八条（留保を認めている又は禁止している条約）

1. 条約の文言により認められた留保は、条約に別段の定めがない限り、利害關係国による受諾なしに有効である。

2. すべての利害關係国により、明示的に同意されない限り、次の場合には留保は認められない。

(a) 留保の表明が条約又は国際組織の確立した規則により禁止されている場合

(b) 条約が当該留保を含まない特定の留保の表明を明示的に認めている場合⁽¹⁰⁰⁾」。

この条文は、旧第一八条一項の(a)から(c)までと旧第二〇条一項(a)を一つにしたものであり、内容的には、特に変更された箇所はない。ただ、この規定方式により、条約が留保について何らかのことを規定している場合には、原則として、事後の受諾又は異議は必要ではないということが、より明確になっている。

次に、留保に關して沈黙している条約の場合を扱った第十九条は、次のように規定されていた。

「第十九条（留保に關して沈黙している条約）

条約法条約における留保の「有効性」の決定について(一)

1. 条約が留保の問題に關して沈黙している場合には、留保は、条約の趣旨及び目的と両立していることを条件として、提案することができる。かかる場合における留保の受諾又は拒否は、以下の項の規則により決定されなければならない。

.....

4. その他の場合には、關係国が別段のことを明示的に述べない限り、

(a) 留保を付した国は、留保を受諾するいずれの当事国との關係においても、条約の当事国關係に入る。

(b) 留保に對しいずれかの当事国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該当事国との間における条約の効力発生は妨げられる⁽¹⁰⁾。

本条は、旧第一八条一項(d)と旧第二〇条一項(b)から第二〇条四項までを一つの条文にまとめた形になっているが、本条については、若干の説明が必要と思われる。

本条の一項は「積極的な方法で、旧第一八条一項(d)に含まれていた規則を再述しており、……両立性の基準を、留保を提案する自由に対する制限として維持している⁽¹⁰⁾」とされる。もともと、本条の四項(a)では、両立性の基準は、受諾の明示的条件として明記されていない。ウォルドックは、その点につき、先のイギリス政府のコメントに言及しつつ、次のように説明している。「委員会は、……強制的な審査機関がない限り、両立性の基準を適用する唯一の手段は、個別国家による留保の受諾又は拒否によってであると感じた。留保を明示的に受諾する国又は留保に對して異議を申し立てていない国は、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しているとみなしていると推定されなければならない。かかる推論は、新第一九条一項(旧第一八条一項(d))が『趣旨及び目的と両立する』留保のみが許容されること

を予定しているという事実から、自動的に導かれるものと思われる^(四)。すなわち、もはや自明のことなので、両立性の基準を明記する必要はないということであり、そのような意図であればさほどの問題はないだろう。むしろ問題は、本条の四項(b)であり、そこでは旧第二〇条二項(b)にはあった限定句が削除されていたのである。その点については、次のように説明されている。「一方で、条約の沈黙は、条約の趣旨及び目的と両立する留保の表明に対する同意を暗に意味し、その場合には、特定のそうした性質を有する留保に対する同意は事前に与えられているとみなされ」うるが、「他方、同様に、条約の沈黙は、『両立する』留保の提案に対する同意にすぎず、その場合には、特定の留保に反対する権利が維持される」とみなすこともできるとし、結局、ウォルドックは「後者の見解が既存の慣行を反映しているものと信じ」、本項にも両立性の基準は明記されなかったのである^(四)（傍点筆者）。

委員会は、ウォルドックの「純粹に合意に基づく制度」を、完全には受け入れず、両立性の基準が許容性の基準として挿入されるようになったことは、上述の通りである。また、その関係で、ウォルドックが絶対的と考えていた、異議を申し立てる権利が制限されることになった。しかし、この第四報告書では、再び異議は絶対的な権利であることが確認されている。こうした趣旨のコメントが、いくつかの政府から寄せられたことが、ウォルドックを勇気付けたのだろう。しかしながら、その結果、いずれかの国が留保を提案した場合、他の国には、以下の三つの選択肢があることになってしまい、条文草案はいささか複雑になってしまったように思われる。すなわち、第一に、当該留保を受諾する、第二に、当該留保を両立しないものとみなし異議を申し立てる、第三に、当該留保を両立しないとはみなさないが、その他の理由（例えば政治的な理由）で異議を申し立てる、の三つである。このうち、留保を受諾する場合については、常に留保の両立性が推定されるので、理論的にはそれほど問題ではない。しかし、留保に対して異議

を申し立てる場合には、両立性が推定される場合と推定されない場合があることになってしまう。ウォルドックは、「仮に非両立性以外の理由で異議を申し立てたとしても、通常は同時に非両立性も認定する⁽¹⁰⁶⁾」と考えていたが、国家が常にそうしなければならない義務を負うわけではない。異議が両立性の判定にも関係することに鑑みれば、二つの異議を別個に規定するほうが、より明快であったように思われる。またその印象は、第一九条四項の冒頭の但書きにより、一層強まる。留保の非両立性を理由として異議が申し立てられた場合で、異議国が別段のことを明示的に述べる時、当該留保はいかなる帰結を生ずるのか。ウォルドックの第四報告書では、「留保の適用」と題された第二一条の冒頭句を「第一八条から第二〇条までの規定により、有効なものとして成立した留保は、次のように機能する」と修正する必要があることが示唆されていた⁽¹⁰⁶⁾。これを文字通りに解釈すれば、有効に成立していない両立しない留保には、本条は適用されないことになる。しかし、では、いかなる帰結を生ずることになるのか。残念ながら、この点については、ここでも何らの示唆もなされなかった。

以上のような第四報告書であったが、国際法委員会ではどのように受けとめられたのだろうか。

(4) 国際法委員会一九六五年の審議

国際法委員会は、一九六五年の第七九六会合から再度留保に関する審議を開始したが、まず問題となったのは、審議の基礎を、一九六二年の委員会仮草案とするか、それともウォルドックが第四報告書で作成した代替草案とするかということであった。この点については、委員の間で一致がみられず、結局は、各委員の裁量に任されることになった⁽¹⁰⁷⁾。

さて、その結果、ウォルドックの、代替草案の目的は一九六二年草案の内容を変更することだったわけではない、

という発言にも関わらず、「留保を表明する権利を述べる方法というもっぱら心理的と思われる問題」に関して、委員会内で対立が生じることになってしまった。⁽¹⁰⁸⁾ それゆえ、議論はもっぱら形式面に集中し、肝心の内容についての議論はあまりなされなかった。もともと、このことは逆に、もはや内容上の差異は、両草案の間にはさほどなかったという委員の認識を表していると思われることができるかもしれない。実際、そのことを指摘する委員の発言を見出すことができるし、ウォルドック自身もそのように審議を総括している。⁽¹⁰⁹⁾ とはいえ、内容に関する審議が全くなされなかったというわけでもないで、いくつか目についたものを見てみることにしよう。

まず、アゴーは、代替草案の第一九条二項を「条約が沈黙している場合には、条約の趣旨及び目的と両立しない留保の表明は禁止されるという原則を明示的に規定した」と肯定的に評価している。また、ロゼンヌは、政府のコメントに納得し、もはや「両立性の基準を……異議にも適用されるべきであるとは主張しない」と述べている。⁽¹¹⁰⁾ しかし、こうした肯定的な評価がある一方で、ブリッグスは、代替草案第一九条一項の「かかる場合における」の意味について質問し、「それらの文言が、その項の第一文に照らして、……両立する留保の場合に言及しているのならば、二・三・四・五項は、提案された留保が……両立していない場合には、適用されないということになるように思われる。その時、条約の趣旨及び目的との非両立性以外の理由で、留保に対して異議が提起された場合に、適用されるべき規則はいかなるものか」という点を、ウォルドックに問いただした。⁽¹¹¹⁾ もともと、ウォルドックは「両立性以外の理由でも異議を申し立てることはできる」、⁽¹¹²⁾ とやや的外れと思われる返答をしただけであつた。

以上が数少ない内容についての発言及び質疑である。結局、異議は絶対的権利であるというウォルドックの考え方は、最終的には委員会でも承認されたと見るべきなのだろう。それならば、二種類の異議の帰結の差異を明確にすべ

きであったと思われる。しかし、そうした趣旨の発言は、前述のブリッグスの質問には多少その意図が窺われるが、それ以外には聞かれなかった。

さて、結局、仮草案と代替草案における規定形式の相違をめぐる対立は最後まで決着がつかず、ウォルドックが一般的な支持を得た見解を基礎に再起草することになり、それを起草委員会に付託することになった⁽¹⁵⁾。そして、起草委員会での審議を経て、委員会に次のような条文が提出された。

「第一条（留保の表明）

いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、条約への加入、条約の受諾若しくは承認に際し、留保を付することができる。

- (a) 条約又は国際組織の確立した規則が当該留保の表明を禁止している場合
- (b) 条約が当該留保を含まない特定の留保の表明を認めている場合
- (c) 条約が留保に関する規定を含んでいない場合には、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合⁽¹⁶⁾。

一見してわかるように、形式的には、仮草案のそれが採用された。これは概ね好意的に受けとめられたが、(b)項の範圍⁽¹⁷⁾や両立性の基準の適用範圍⁽¹⁸⁾をめぐる、若干の委員から意見が出され、再度起草委員会へ付託されることになった⁽¹⁹⁾。また、ウォルドックによれば、仮草案の形式を維持しつつ、代替草案の多くを採用したとされる第十九条は、次のようになった。

「第十九条（留保の受諾及び留保に対する異議）

1. 条約により明示的に又は黙示的に認められた留保は、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による後からの受諾を要しない。

.....

4. 1から3までの場合以外の場合には、

(a) 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときにはその受諾の時に、条約の当事国関係に入る。

(b) 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生は妨げられる。ただし、当該他の締約国が別段の意図を表明する場合は、この限りでない⁽¹²⁾。

本条も概ね各委員の支持を得ているようだった。とはいえ、二項について、若干の委員から意見がだされ、起草委員会へ差し戻されることになった。

再度起草委員会により作成された条文では、実質的な変更は全くなく、単に起草上の変更しかされなかったので、票決となった⁽¹³⁾。いよいよ舞台は外交会議へと移ることになったのである。なお委員会最終草案では、第一八条は第一六条に、第一九条は第一七条になった。

以上のように、委員会の最終草案では、形式的には、ウォルドックが第四報告書で作成した代替草案は採用されなかった。しかし、上述したように、それは単に形式に留まるのであって、内容的にはほとんど差違はないと思われる。それゆえ、代替草案についてのウォルドックの説明は、最終草案にもほぼ当てはまると筆者は考える⁽¹⁴⁾。

それでは、外交会議では、どのような議論がなされたのだろうか。外交会議の検討に移ることにしよう。

(二) 外交会議での議論

外交会議において、旧ソ連圏諸国の異議の推定を逆転させようとした試みが成功したことや日本・韓国・フィリピンが、共同で両立性の判定について集団判定制度を導入することを要求したこと、及び現第十九条(b)項に「only」が挿入されたことは、あまりにも有名である。⁽¹²⁵⁾ そのためか、アメリカ政府が第一七条四項に対して提出した修正案には、ほとんど言及されていない。

アメリカ政府は、第一七条四項の冒頭句に対して、次のような修正案を提案した。

「一から三までの場合以外の場合で、当該留保が第一六条により禁止されていない場合には」⁽¹²⁶⁾ (傍点筆者)。

アメリカ代表ブリッグスは、この修正案により「他の締約国は条約により禁止された留保を受諾することを妨げられることになり、第二六条(c)項に規定された条約の趣旨及び目的との非両立性という基準が、かかる受諾又は異議に適用されることになるう。(c)項の欠点は、……かかる基準が留保に対する受諾又は異議に適用可能であることが明示的になされていない点にある」と述べていた。⁽¹²⁷⁾

このアメリカ修正案の趣旨は理解できる。確かに、委員会最終草案には、第一六条と第一七条との明示的な対応関係が欠落しており、第二六条により許容されない留保でも、第一七条により受諾されてしまうという印象を与えてしまう恐れがあったことは否めない。それが委員会の意図でなかったことは、これまで繰り返し確認してきたように明らかであるが、誤解を招きやすい表現であったことは確かであり、対応関係の明確化を求める必要性をいくつかの国が感じたことは十分に理由のあったことだと思われる。⁽¹²⁸⁾ 逆に、その意味では、これは条文の実質的内容に影響を及ぼす修正案ではない。もっとも、アメリカ修正案では、対応関係を明確にするために異議の理由を非両立性に限定しよ

うという意図が見られるので、その点に関しては修正と言える。

さて、こうした意図をもって提案されたアメリカ修正案であるが、外交会議では、ほとんど注目されなかった。しかし、そのことは第一六条と第一七条の対応関係に影響を及ぼすものではない。というのも、各国の関心が、もっぱら両立性の基準を客観的に適用する方法に向けられ、むしろ第一六条(c)に対しては、第一七条四項の適用を排除すべきか否かという点が大きな争点になったからである。そうした第一七条四項の適用を排除し、両立性の基準の適用にあたって、可能な限り客観性を確保しようとした試みが、日本などが提案した集団判定制度であったことは言うまでもない。すなわち、対応関係については既に十分明白であり、だからこそ実際の適用上生じうる問題に焦点が当てられたのである。⁽¹²⁹⁾ 会議に顧問として参加していたウォルドックの発言にもあるように、まさに「問題は適用の方法」にあったのである。⁽¹³⁰⁾ 周知のように、集団判定制度を導入する試みは失敗に終わったので、アメリカ修正案は採択されなかったものの、対応関係については、外交会議でも変更を受けなかったと見ることができる。また、異議の理由も、最終草案と同じく、非両立性に限定されないことが確認された。⁽¹³¹⁾ しかし、委員会仮草案の段階からの問題である、ある留保を両立しないとみなし異議を申し立てる国が、条約の効力発生を選択した場合の当該異議の帰結という問題は、残念ながら外交会議でも全く関心を集めなかった。

(三) 小 括

さてあえて繰り返しを恐れず、前章で指摘した二つの問題、すなわち(1)留保の許容性は何を基準に判定されるのか、(2)両立しない留保にも第二一条三項が適用されるのか、につき、条約法条約がどのような立場をとっていたかを確認

しておきたい。その上で、それと両学派の見解とを対照させてみることにする。

第一の問題についての条約法条約の立場は、次のようであつた。まず、第一九条(a)及び(b)に該当しない留保は、当然に有効である。なぜなら、締約国は当該留保を事前に受諾しているからであり、他の締約国が当該留保を受諾又はそれに対し異議を申し立てるといふ対抗力の問題は、条約の締結過程で既に解決されているからである。第二〇条一項は、そのことを確認しているにすぎない。次に、第一九条(c)に該当しない留保、すなわち両立する留保は、それを提案することを許されるにすぎず、当該留保がいかなる帰結を生ずるかは、他の締約国の対応如何による。他の締約国の対応は、第二〇条二項から四項までの規定に従つてなされなければならない。第三に、両立性の判定は、それについての有権的機関が存在しないことを考慮し、各締約国の受諾又は異議により行われる。従つて、第一九条(c)が適用される条約に対する留保は、第二〇条四項により、両立性の判定が行われる。

以上の三点と両学派の見解を照らし合わせて見よう。まず、第一九条(a)及び(b)に該当しない留保は、他の締約国の対応如何を問わず有効であること、この点については両学派とも一致している。また、条約法条約もそのような考えで起草されたのであり、この点については特に問題はないだろう。

次に、両学派の見解の異なる第一九条(c)の場合について見てみよう。まず、留保の両立性という許容性の問題は、他の締約国の当該留保に対する受諾又は異議という対抗力のそれとは何の関係もないという許容性学派の見解は、条約法条約が本来想定していたものとは異なる。条約法条約は、この場合には、対抗力の問題が許容性のそれに決定的な影響を及ぼし、対抗力を有する留保(受諾された留保)は両立する留保であり、従つて有効である、と推定されるという考えで起草されたのである。換言すれば、留保の許容性は対抗力の有無から推定され、それにより「有効性」

が決定されるのである。繰り返し述べてきたように、両立性の判定についての有権的機関が存在しないことから、この一見倒錯したように見える考えを採用せざるをえなかったのである。条約法条約がこのような考えで起草されていた以上、アンペール以外の対抗力学派の見解はそれをより忠実に再述していると言える。もともと、この点に限って言えば、国際法委員会でのアゴートとトゥンキンの議論に見られるように、純粹に觀念的な対立と見ることもできよう。ただし、条約法条約では、原則として、留保の受諾は、当該留保の両立性を意味すると考えられている。それゆえ、本来、全く異議が申し立てられていない場合には、裁判所等の第三者機関が、当該留保の許容性に疑いを差し挟む余地はない。しかしながら、詳細は次章に譲ることにするが、実際には、そのような場合にも、留保の許容性を問題にし、かつ当該留保を無効にするという事例が既に存在している。条約法条約が本来想定していた考えとは異なる許容性学派の見解が、今なお完全に否定されていないのは、現実が生じている事例を説明するのに適しているからだとも言えよう。⁽¹³⁾

次に第二の問題についてであるが、これは、ある意味では、第一の問題よりも重要であろう。それは、条約法条約の留保制度の根幹に関わる点であり、両立する留保と両立しない留保が結局は同一の帰結を生じるのであれば、両立性の基準の意味がほとんど失われてしまうからである。しかし残念ながら、この点についての条約法条約の立場を特定することは難しいように思われる。起草過程からは、以下のことを確認することができるにすぎない。まず、前提として、第一の問題との関連で見たように、ある留保が両立しているか否かは、他の締約国の受諾又は異議により決定される。そして、受諾は当該留保の両立性を意味するが、異議は、理由の如何を問わず申し立てることができるので、必ずしも当該留保の非両立性を意味しない。つまり、異議には、両立する留保に対する異議と両立しない留保に

対する異議が存在することになる。そして、前者の異議の場合、異議国が留保国との間における条約の効力発生に反対しない場合には、当該異議には第二一条三項が適用される⁽¹³⁾。ここまでは起草過程から明らかである。しかし、後者の異議が申し立てられた場合で、異議国が留保国との間における条約の効力発生に反対しない場合、当該異議によりいかなる帰結がもたらされるかという問題は、起草過程ではほとんど議論されなかった。従って、ガヤツエマネックが言うように、両立しない留保に対する異議にも、第二一条三項が適用されるという解釈を許す余地も残されているように思われる。

さて、いずれにしても、起草過程を見ただけでは、これら二つの問題に十分に取り組んだとは言えないであろう。先に触れたように、条約法条約の起草時に採用された立場に反するかのような実行が条約法条約の効力発生後に出現していることや、起草過程からは十分に明確にならなかった点が残っていることに鑑みれば、条約法条約採択以降の国家実行及び国際判例を検討せざるをえない。

- (1) General Comment Adopted by the Human Rights Committee under Article 40, of the International Covenant on Civil and Political Rights: Addendum General Comment No. 24 (52) (hereinafter cited as General Comment), CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6. 立場の如何を問はず、¹³の意見と言及する論稿は「*William A. Schabas, "Reservation to Human Rights Treaties: Time for Innovation and Reform," The Canadian Yearbook of International Law*, 1994, pp. 39-81, *ibid.*, "Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Is the United States still a Party", *Brooklyn Journal of International Law*, 1995, Number 2, pp. 277-325, Thomas Giegerich, "Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit, Gültigkeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien, Ein konstitutioneller Ansatz", *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1995, 55/3, SS. 713-782, Gérard Cohen-Jonathan, "Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits de l'homme. Nouveaux aspects européens et interna-

tionaux”, *Revue Générale de Droit International Public*, 1996-4, pp. 915-949, Catherine Redgwell, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee General Comment No. 24 (52)”, *International and Comparative Law Quarterly* (hereinafter cited as *I. C. L. Q.*), Vol. 46, 1997, pp. 380-412. 我が国においては、安藤仁介「自由権規約委員会——人権関係条約に対する留保について——」『国際人権』No. 6、六三—六六頁（以下、安藤「前掲論文（国際人権）」として引用）、同「人権関係条約に対する留保の一考察——規約人権委員会のジェネラル・コメントを中心に——」『法学論叢』第一四〇巻一・二号（以下、安藤「前掲論文（法学論叢）」として引用）、一—二四頁がある。

(2) General Comment, *supra* note. 1, paras. 17 and 18.

(3) *Ibid.*, paras. 3 and 6.

(4) 地域的人権条約の実行については、既にわが国にも多数の論稿がある。薬師寺公夫「人権条約に付された留保の取り扱い」『国際法外交雑誌』第八三巻第四号、一—六〇頁（以下、薬師寺「前掲論文（留保）」として引用）、同「人権条約に付された解釈宣言の無効」『立命館法学』（一九九〇年二号）、九五—一五〇頁（以下、薬師寺「前掲論文（解釈宣言）」として引用）、佐藤文夫「条約法に関するウィーン条約の留保規則（一九条及び二〇条）についての若干の考察——米州人権裁判所勧告的意見No. OC2/82をふまえて——」（一）（二）『成城法学』第一六号、六五—七七頁、『同上』第三号、五九—九一頁。（以下、それぞれ佐藤「前掲論文（一）」「前掲論文（二）」として引用）。

(5) 代表的なものとして、Pierre-Henri Imbert, “Reservations to the European Convention on Human Rights Before the Strasbourg Commission: The Temelash Case”, *I. C. L. Q.*, Vol. 33, July 1984.

(6) 例えば、薬師寺「前掲論文（留保）」注（4）、三八頁。本文でも指摘したように、地域的人権条約の実施機関による実行は、十分確立しているように思われる。例えば、ヨーロッパ人権裁判所は、初めて留保の許容性判定に踏み切ったプリロ事件以降も、ヴェーバー事件、コールヘル事件、グラディンガー事件でも、許容性の判定を行っている。Eur. Court H. R., *Belilos Judgment of 29 April 1988*, Series A no. 132, *ibid.*, *Weber judgment of 22 May 1990*, Series A no. 177, *ibid.*, *Chorherr v. Austria judgment of 25 August 1993*, Series A no. 266-B, *ibid.*, *Gradinger v. Austria judgment of 23 October 1996*, Series A no. 328-C, *いふの判例について*, Gerard Cohen-Jonathan, *supra* note. 1, pp. 921-929. また、米州人権条約との関係でも、今の所特に締約国から異議が提起された形跡は窺われない。

条約法条約における留保の「有効性」の決定について（一）

(7) その意味で、従来の議論を批判的に考察し、人権条約に対する留保という主題の再構成を試みているハレの第二報告書は重要である。Alain Pellet, "Second Report on Reservations to Treaties", A/CN.4/477/Add.1 既記。我が国でもハレの報告書に言及する論稿が公表されている。坂元茂樹「人権条約と留保規則——国連国際法委員会の最近の作業を中心に——」

『国際人権』No.9、二九—三三頁。

(8) 本稿では、有効性という用語を、引用箇所でない限り、括弧付きで用いる。後述(本稿二を参照)するように、この用語の使用及びその意味が争われており、そのまま用いれば、当初から筆者が一方の学派に賛同しているという誤解を与えうるからである。筆者は、あくまで中立の立場で本主題に取り組んだことを強調しておく。

(9) Alain Pellet, "First Report on Reservations to Treaties", A/CN.4/470, pp. 47-58. 及び、坂元茂樹訳「条約の留保に関する法及び実行についての第一報告書(一)」『関西大学法学論集』第四六巻第一号(一九九七年)一三四—一四三頁。

(10) Pellet, *supra* note. 9, pp. 49-50, para. 104. 坂元「前掲訳」注(9)一三六頁。

(11) Pellet, *supra* note. 9, pp. 49-50, para. 104. 坂元「前掲訳」注(9)一三六頁。訳出に当たっては、坂元訳を参考にしつつ、若干の修正を加えた。

(12) 詳しくは、本稿二を参照。

(13) 我が国において、両学派の見解を紹介したものには、梅田徹「条約の留保の有効性をめぐる学派対立——permissibility school と opposability school——」『麗澤大学紀要』第六四巻(一九九七年)がある。

(14) Jean Kyongun Koh, "Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World Vision," *Harvard International Law Journal*, Vol. 23, 1982, p. 97.

(15) *Ibid.*, p. 76. ハレの分類は、もっぱらハウエットに従ったものであるとされている。*ibid.*

(16) *Ibid.*, pp. 97-98.

(17) *Ibid.*

(18) コウ自身は、「条文の分析からは、対抗力学派が優勢」とするものの、それ以上のことは述べていない。*ibid.*, p. 99 (n. 102).

(19) Catherine Redgwell, "Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties,"

British Yearbook of International Law (hereinafter cited as *B. Y. I. L.*), Vol. 64 (1993), p. 263.

- (20) D. W. Bowett, "Reservations to Non-restricted Multilateral Treaties," *B. Y. I. L.*, Vol. 48 (1976-1977), p. 70.
- (21) *Ibid.*, p. 81.
- (22) *Ibid.*
- (23) *Ibid.*, pp. 84-87.
- (24) *Ibid.*, pp. 82-84.
- (25) *Ibid.*, p. 78 and 88.
- (26) *Ibid.*, pp. 75-80. ただし、国家の意思をどのように区別するにせよ、実際上可能なのかという疑問は当然提起される。その点も含め、この区別に対する批判については、Redgwell, *supra* note 19, pp. 267-268. なお、選択条項に対する留保の条約法の適用性については、杉原高嶺『国際司法裁判制度』有斐閣、平成八年、一四九—一五二頁。

(27) Bowett, *supra* note 20, p. 88.

(28) Koh, *supra* note 14, p. 76.

(29) Pellet, *supra* note 9, p. 50, para. 105. 坂元「前掲記」注(9)′ 一三五—一三六頁。

(30) Pellet, *supra* note 9, p. 47, para. 97. 坂元「前掲記」注(9)′ 一三四頁。なお、イギリス政府も「有効性」という文言の使用に反対しているものとせよ。Pellet, *supra* note 9, p. 47, para. 98. 坂元「前掲記」注(9)′ 一三四—一三五頁。

(31) Redgwell, *supra* note 1, p. 404ff., *ibid.*, *supra* note 19, pp. 263-269. 佐藤「前掲論文(11)」注(4)′ 八五—八七頁。

(32) ヴンダ¹⁾、以下の論議を挙げて、Pellet, *supra* note 9, p. 49, n. 209)° J. M. Ruda, "Reservations to Treaties", *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1975-III, Tome 146, p. 190, Jean Combacau, "Le droit des traités", P. U. F., "Que sais-je?", No. 2613, Paris, 1991, p. 60, Giorgio Gaja, "Unilateral Treaty Reservations", *Le Droit international a l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Giuffrè, Milan, 1987, Vol. I, pp. 313-320, Pierre-Henri Imbert, *Les réserves aux traités multilatéraux*, Pedone, Paris, 1979, pp. 134-137, Paul Reuter, *Introduction au droit des traités*, P. U. F. I. U. H. E. I., Paris, 1985, p. 74, Karl Zemanek, "Some Unresolved Questions concerning Reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties", *Etudes de droit international en l'honneur du Juge Manfred Lachs*, Nijhoff, The Hague,

条約法条約における留保の「有効性」の決定について

いるのは、許容性 (permissibility) はいかに確立されるかという点である。これに対して、クラークの分類は、留保の「有効性」には、二つの要素すなわち許容性と対抗力が必要であるという見解では、両立する (許容される) 留保であっても、なお他の締約国は受諾又は異議を選択することができるという観点からなされている。すなわち、許容性 (permissibility) はすでに確立しているが、それが他の締約国に対して対抗力を有するか否かという点に焦点を当てているのである。確かに、クラークが言うように、両立する留保であっても、他の締約国はなお受諾又は異議の選択権を有し、必ず受諾しなければならぬわけというわけではない、という見解を示している点では、ルダとパウエットは一致しているが、ペレが「go hand in hand」と述べているのはその点ではない。このようにペレとクラークとは、対象としている土俵が異なるのであり、両者が同一の対象について異なる見解を有するかのような説明は誤解を招きかねない。なお、クラークの見解については、Belinda Clark, "The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women", *American Journal of International Law*, Vol. 85, 1991, pp. 302-308.

- (40) Reuter, *supra* note. 32, p. 74, Combacau, *ibid*, pp. 59-60. 我が国においては、小川芳彦『条約法の理論』東信堂、一九八九年、二二三—二三〇頁、福田吉博「『両立性の基準』とウィーン条約法条約」『法と政治』第四一卷第一・三号、三七六頁。なお、シンクレアは、抽象的な論理としてはパウエットの説に説得力があることを認めつつ、実際の観点からはルダの説を肯定しつつも、Sir Ian Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties* (Manchester University Press, 2nd ed., 1984), pp. 81-82.

- (41) Imbert, *supra* note. 32, p. 134.

- (42) *Ibid*, pp. 134-135. なお、アンセルは、こうした結論に至らざるを得ないことに疑問を感じ、なぜ第一九条(c)項は、国際法委員会及び外交会議で承認されたのだろうかという問いを発している。その結果、第一に、外交会議での起草委員長であったヤシーンの言葉を引用して、両立性の基準がその時点で「慣例的用語」になっていたこと、第二に、このような矛盾は、様々な見解を調整しなければならぬ「全ての法典化会議の定めである」との答えを見出している。*ibid*, p. 140.

- (43) Zemanek, *supra* note. 32, p. 331.

- (44) *Ibid*, pp. 331-332. それゆえ、ツェマネックは、許容されない留保に対する異議は、一般国際法上の抗議と同様の効果を有するにすぎないと考えている。*ibid*, p. 332.

条約法条約における留保の「有効性」の決定について (一)

- (45) Gaia, *supra* note. 32, pp. 314-315.
- (46) *Ibid.*
- (47) *Ibid.*, p. 315.
- (48) *Ibid.*, p. 318.
- (49) *Ibid.*
- (50) *Ibid.*, pp. 315-318.
- (51) もっとも、(a)項及び(b)項に反する留保が、いかなる効果を及ぼしうるかという点については一致していない。例えば、ガヤは、パウエットの見解 (*supra* note. 26) を「なぜ留保の性質が決定的要素とみなされなければならないのか、理解しがたう」と批判している。Gaia, *supra* note. 32, p. 313.
- (52) ウォルドック草案以前の国際法委員会の作業及び留保に関する一般的な考察については、小川『前掲書』注(40)、六九—一八〇頁。福田「前掲論文」(同上)「三四九—三五八頁」。
- (53) Sir Humphrey Waldock, "First Report on the Law of Treaties", A/CN. 4/144, *Yearbook of the International Law Commission* (hereinafter cited as *Y. B. I. L. C.*), 1962, Vol. II, pp. 60-62.
- (54) *Ibid.*, p. 65, para. 9.
- (55) *Ibid.*
- (56) これは、かつてフィッツモーリスが提示した見解に酷似している。フィッツモーリスは、「留保権と留保反対権とを同一平面において論ずることに反対し、すでに確定した条約文にたいして一方的に留保を行う権利などは存在しないと述べ、たとえそのような留保が寛容されたとしても、それはその留保に明示又は黙示の同意が与えられることによって成立する合意の問題であって、留保を希望する国の権利の問題ではないとし、結局存在しているのは留保に反対する権利だけであり、かつその権利は原則として絶対的なものである」と説いた。小川『前掲書』注(40)、一四四頁。Sir Gerald Fitzmaurice, "Reservations to Multilateral Conventions", *J. C. L. Q.*, Vol. 2, Pt. 1, 1953, p. 13. ただし、小川も指摘しているように、フィッツモーリスの説は、条約の一体性の尊重を主張する論者には、無理なく受け入れられるが、条約の普遍性を重視する論者からは、「一国またはごく少数の国の反対によって留保申出国の条約参加を拒否するのは権利濫用である」という批判を招き

うる。小川『同上』、二二四—二二五頁。そこで、ウォルドックは、基本的には、フィッツモーリスの説を採用する一方で、こうした批判をも考慮し、留保の受諾形式としては汎米慣行形式を採用することによって、均衡を保とうとしたように思われる。結果的に、この試みが成功したか否かについては、本稿の結論を参照。

(57) Waldock, *supra* note 53, p. 65, para. 9.

(58) *Ibid.*, para. 10.

(59) *Ibid.*, pp. 65–66, para. 10.

(60) *Ibid.*, p. 66, para. 10.

(61) *Ibid.* その困難につき、ウォルドックは(1)同意原則という客観的な基準が、他の主観的かつ不確定な基準により無視又は制限されるのであれば、単純かつ客観的な基準としてのその価値をほとんど失うことになること、(2)いくつかの場合には、二つの基準は相反する結果を生じうることを挙げている。*ibid.*

(62) *Ibid.*

(63) 佐藤文夫も同様の見解を示している。佐藤「前掲論文(二)」注(4)、六四頁。

(64) 佐藤「同上」。

(65) Pellet, *supra* note 9, p. 21, para. 45. 坂元「前掲訳」注(9)、一二九頁。

(66) 周知のことではあるが、「二国間条約及び少数国間条約については、それぞれ草案第一九条四項(a)と(b)で、引き続き全会一致の原則が採用されていた。Waldock, *supra* note 53, p. 62. 小川『前掲書』注(40)、一三七頁。

(67) Waldock (651st meeting, para. 3), Y. B. I. L. C., 1962, Vol. I, p. 139.

(68) 小川『前掲書』注(40)、一三七頁。

(69) 小川『同上』、一三七—一四二頁、及び、福田「前掲論文」注(40)、三五八—三六七頁。

(70) Rosenne (651st meeting, para. 79), *supra* note 67, p. 145. 確かに、ロゼンヌが言うように「特に、第一九条にその基準を適用すれば、異議並びに留保そのものに対して両立性の基準を適用した、ジェノサイド事件における問題Ⅱに関する……国際裁判所の意見に対応するものになるであろう」。 *ibid.* see, *Reservations to the Convention in Genocide, Advisory Opinion: I. C. J. Reports 1951, p. 18.*

- (71) Briggs (651st meeting, para. 23), *supra* note 67, p. 140, Lachs, (651st meeting, paras. 54-55), *ibid.*, pp. 142-143, Ago (651st meeting, para. 57), *ibid.*, p. 143. フリックスとマコーは共に「適用の困難を理由に挙げていた。また「ラックスは「留保の両立性は「国際司法裁判所に決定されるべきである」という前特別報告者のローターバクトが一九五三年の報告書で提案した四つの代案の内の一つに疑問を發し「両立性の決定は「条約の主人々 (masters) である当事国によりなされるべきである」と發言しつつだ。Lachs, (651st meeting, para. 55), *ibid.*, p. 143. ローターバクト草案については、Y. B. I. L. C., 1953, Vol. II, p. 134. なお「フリックスは「留保が条約当事国の三分の二により承認されない限り「多数国間条約に留保を付すこととすべきなら」という制度を推奨していた。Briggs (651st meeting, para. 26), *supra* note 67, p. 140. 彼は「この制度にかなりのこだわりを示していたが、周知のように採用されなかった。

- (72) Waldock (651st meeting, para. 85), *ibid.*, p. 145.

- (73) Passou (653rd meeting, para. 9), *ibid.*, p. 154, Tunkin (653rd meeting, paras. 23 and 26), *ibid.*, p. 156, Rosenne (653rd meeting, para. 28), *ibid.*, p. 156.

- (74) Waldock (654th meeting, para. 15), *ibid.*, p. 162.

- (75) Waldock (663rd meeting, para. 3), *ibid.*, p. 221.

- (76) Waldock (663rd meeting, para. 27), *ibid.*, p. 223.

- (77) Tsuruoka (663rd meeting, para. 28), *ibid.*, p. 223. 上の関連で、佐藤文夫は「両立性基準の性格付けは、両草案とも実質的に同一と考えられよう」と述べているが、この鶴岡の發言からすれば、この解釈には疑問が残る。佐藤「前掲論文(二)」注(4)「六五頁。

- (78) Waldock (663rd meeting, para. 61), *supra* note 67, p. 225. なお「三項は国際機関の設立文書、四項は少数国間条約の場合が規定されている」と *ibid.*

- (79) *Ibid.*

- (80) Rosenne (663rd meeting, para. 40), *ibid.*, p. 224.

- (81) Castrén (663rd meeting, paras. 70-71), *ibid.*, p. 226. なお「カストレンは「第一七条の規定に従って付され、条約により明示的に認められていながら留保の有効性は、本条の二項から四項までの規定に従うことを条件として、留保の受諾如何に関

わる。」という修正案を提示していた。

- (82) Verdross (663rd meeting, para. 63), *ibid.*, p. 226. フェアドロスは「第一八条 bis 一項(b)と第一七条一項(d)の間には、
はなはだしい矛盾がある。よくなる状況においても、条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、受諾されえない。」と述べ
た上で、第一八条 bis 一項(b)の冒頭に「留保と条約の趣旨及び目的との両立性に関して疑いのある場合には」という一節
を挿入するよう求めた。

- (83) Ago (663rd meeting, para. 79), *ibid.*, p. 227.

- (84) Tunkin (663rd meeting, para. 82), *ibid.*, p. 227. テ・ルナールの見解に同意していた。de Luna (663rd meeting, para. 84),
ibid., p.227.

- (85) Ago (663rd meeting, para. 86), *ibid.*, p. 228. なお、アゴーのこのような立場は、審議の前半で示されたそれとはかなり異
なっている。自らの立場を変更した理由は述べられていないが、やはり起草委員会が提案した条文での両立性の基準の性格
付けの変更が影響を及ぼしたように思われる。

- (86) Ago (664th meeting, para. 21), *ibid.*, p. 231.

- (87) Tunkin (664th meeting, para. 23), *ibid.*, p. 231.

- (88) *Ibid.*

- (89) Waldock (656th meeting, para. 2), *supra*, note. 67, p. 172.

- (90) Waldock (667th meeting, para. 55), *ibid.*, 252.

- (91) 実際「ロゼンヌの文に理解」づけ。Roseme (656th meeting, para. 66), *ibid.*, p. 253.

- (92) 同様の評価が、Pellet, *supra* note. 9, pp. 20-21, para. 44, 坂元「前掲訳」注(9)、「二一九頁」に見られる。

- (93) なお、表題も変更されているが、それについては何の説明もなされなかった。従って、この規定の解釈上、どのような影
響を及ぼすかは定かでないと思われる。しかし、佐藤文夫は、この表題の変更が「両立性基準のガイドライン性格の変質を
語るものと思われる」とし、「これは、留保の有効性の問題と受諾又は異議の問題を分離しようとするもの」と見ている。
佐藤「前掲論文(二)」注(4)、「六六及び八五頁。その根拠として、起草委員会の最初の草案に関して、「留保表明規定(一
七条一項)自体が留保の有効性(validity)の問題を扱っているのであって、一八条のこの規定で左右されるものではなく、

条約法条約における留保の「有効性」の決定について」

後者は留保の受諾及び留保に対する異議の効果に關係しているにすぎないとして、一八条の二、一項の削除提案を行った」とされるバルの発言を引用し、それが草案に採り入れられたために、表題の変更が必要であったと見ている。佐藤「同上」八五頁。確かに、バルは引用部分のような発言をしているが、ここから留保の有効性の問題（文脈から言えば、許容性の問題としたほうが適切と思われるが）と受諾又は異議の効果の問題が分離されたという解釈が成立するだろうか。というのも、本文でも触れたように、分離されたというよりは、むしろ關係付けが試みられたと見るほうが良いように思われるからである。

- (94) Tunkin (653rd meeting, para. 26), *supra*, note 67, p. 156, Roseene (653rd meeting, para. 30), *ibid.*, p. 157, Jiménez de Aréchaga (653rd meeting, para. 48), *ibid.*, p. 158, de Luna (653rd meeting, para. 66), *ibid.*, p. 160, Yasseen (654th meeting, para. 6), *ibid.*, p. 161.

- (95) Y. B. I. L. C., 1965, Vol. II, p. 46. なお、鶴岡は「委員会での審議の折に、「第一七条に規定された規則と合致しない留保は、当然に無効とみなされなければならないのか否かを知りたい」、「問題は、それらの規定に違反する国の留保が、違法であり、その結果無効であるかということであった。換言すれば、理論的には、無効な留保を維持している国は、条約の当事国になれないが、かかる留保に対する異議は、単に異議国と留保国間の条約の効力発生を妨げるにすぎないのか?」という二つの問かけをした。Tsuruoka (652nd meeting, para. 63), *supra*, note 67, p. 151, Tsuruoka (654th meeting, para. 22), *ibid.*, p. 163. また「バルトシチ委員もそれらの点に関心を示した。Baroš (654th meeting, para. 28), *ibid.*, p. 163. しかし、それらについては何の返答もなされなかった。

- (96) Y. B. I. L. C., *supra*, note 95, p. 47.

- (97) *Ibid.*, p. 46.

- (98) *Ibid.*, pp. 45-47.

- (99) *Ibid.*, p. 50, para. 4.

- (100) *Ibid.*

- (101) *Ibid.* なお、第二項は「ほぼ現行第二〇条二項と」、第三項は同じく第二〇条三項と同一であった。

- (102) *Ibid.*

- (103) *Ibid.*, p. 52, para. 9.
- (104) *Ibid.*, p. 52, para. 10.
- (105) *Ibid.*
- (106) *Ibid.*, p. 55, para. 1.
- (107) 新条文を審議の基礎とすることに賛成した委員には、ウォルドック・ブリッグス・エリアス・アマド・ラックス・カストレン・ロゼンヌ・カディウー (Cadieux) などが、反対した委員には、トゥンキン・フェアドロスがいた。反対理由は、コメントを提出した国は二〇数カ国にすぎないので、それに基づき修正された新条文を審議の基礎とすることは時期尚早であるという点である。Y. B. I. L. C., 1965, Vol. I, pp. 143-144.
- (108) Waldock (798th meeting, paras. 20-22), *ibid.*, pp. 156-157. けれども一九六二年仮草案の第一七条一項が、「いずれの国も……留保を付する国がある」となっていたのに対し、代替草案の第一八条の冒頭句ではそのように規定されていなかったことによる。「留保を付す権利」を強調し、仮草案の規定方式に賛成していたのは、ヤシーン (797th meeting, para. 17, *ibid.*, p. 149)、『トゥンキン (797th meeting, para. 27, *ibid.*, p. 150)』、エル・エリマン (797th meeting, para. 63, *ibid.*, p. 153) などである。また、『フェアドロスが、長期間に渡る討議を経て採択された仮草案を維持すべきであるとして、仮草案に賛成しなかった (797th meeting, para. 36, *ibid.*, p. 151)』。
- (109) Pal (797th meeting, paras. 45-49), *ibid.*, p. 152, Cadieux (797th meeting, paras. 50-52), *ibid.*, pp. 152-153, Amado (797th meeting, para. 53), *ibid.*, p. 153.
- (110) Waldock (799th meeting, para. 15), *ibid.*, p. 165.
- (111) Ago (797th meeting, para. 41), *ibid.*, p. 152. ただし、マーゴウの点を除いては、仮草案の規定方式に賛成していた。*ibid.*, p. 151.
- (112) Roseme (798th meeting, para. 46), *ibid.*, p. 159.
- (113) Briggs (796th meeting, para. 38), *ibid.*, p. 146.
- (114) Waldock (796th meeting, para. 45), *ibid.*, p. 146.
- (115) Waldock (799th meeting, para. 84), *ibid.*, p. 170.

条約法条約における留保の「有効性」の決定について (一)

- (116) Chairman (813th meeting, para. 1), *ibid.*, p. 264.
- (117) ヤシーンは「(b)項について「条約がいくつかの条項に対し留保を認めている」という事実は、他の条項に対する留保が認められないということを意味しない。」とし、「排他的に」という文言が「認めている」という文言の後に挿入されなければならない」と述べ、カストレンもこれに同意した（もともとカストレンは「排他的に」ではなく「のみ」という文言の挿入を要求。効果はヤシーンと同一とされる）。Yassen (813th meeting, para. 11), *ibid.*, p. 264, Castén (813th meeting, para. 13), *ibid.*, p. 264. これに対して、鶴岡はそれらの改正は「単に、留保を付す自由を拡大するものになる」と反対し、ウォルドックもこれに同意しつつた。Tsuruoka (813th meeting, para. 25), *ibid.*, p. 265, Waldock (813th meeting, para. 27), *ibid.*, p. 265. なお、この点について詳しくは、佐藤「前掲論文(一)」注(4)、六七―七四頁。
- (118)ブリッグスは「両立性の基準は、条約が留保に関する規定を含んでいない場合に限定されてはなら」ず、すべての場合に適用されるべきであるとし、冒頭句に「条約の趣旨及び目的と両立する留保を提案することができる。」という一節を挿入すべきと主張していた。Briggs (813th meeting, para. 10), *supra* note 107, p. 264. これに対して、アューは「ブリッグスが示唆した改正は、問題を著しく複雑にする」とし、「疑いもなく適用が困難な両立性の基準は、条約が留保の主題について沈黙している場合にのみ用いられるべきではない」と反論しつつた。Ago (813th meeting, para. 16), *ibid.*, p. 264.
- (119) Waldock (813th meeting, para. 29), *ibid.*, p. 265.
- (120) Waldock (813th meeting, para. 2), *ibid.*, p. 264.
- (121) Chairman (813th meeting, para. 30), *ibid.*, p. 265. なお、五項と六項は、ほぼ現行第二〇条四項(c)と同五項と同一であった。
- (122) ラックスは、第一八条と第一九条との矛盾を懸念し、「第一八条(c)項の下で、国は、条約の趣旨及び目的と両立しない留保の表明を禁止された」が、「第一九条は、留保が有効になるためには、条約のすべての当事国が受諾しなければなら」と規定しており、その結果、第一八条により閉ざされたドアを開放しているように思われる。」と指摘し、「第一九条二項の規定は、当事国数に関連する条約の特徴に強調を置くべきである。」と主張していた。これに対して、ウォルドックは「条約の趣旨及び目的と両立しない留保の表明を禁止している第一八条の規則と留保の受諾に関する第一九条の規定との間に、固有の矛盾が存在するという点で、論理的な困難があることは疑いない。しかし、その矛盾こそが、柔軟な制度の基礎であ

る。」と答えて了った。Lachs (813th meeting, para. 43), *ibid.*, p. 266, Waldock (813th meeting, para. 44), *ibid.*, p. 266. 上の議論そのものは、十分かみ合ったものとは思えないが、ウォルドックの柔軟な制度に対する基本的な観念を垣間見ることができるといふ点では、興味深い。

- (123) 参考までに、第一八条と第一九条一項から四項までの票決状況を記しておく。前者は、賛成一六、棄権一。後者は、一項から三項までは全会一致、四項は賛成一五、反対二。Y. B. I. L. C., *ibid.*, pp. 283-284.

- (124) それゆえ、筆者は、第一九条と第二〇条の間の対応関係は、明確であると考ええる。確かに、「明示の対応関係が存在していない」ことは事実であるが、そのことから「従来の草案とは明らかに異なる……特徴の一つとして一九条と二〇条の対応関係の不明確化又はルース化が結論しうる」とは思えない。佐藤「前掲論文(二)」注(4)、六七―六八頁。

- (125) これらについては、福田「前掲論文」注(40)、三六八―三七二頁、佐藤「前掲論文(二)」注(4)、六七―七〇頁。

- (126) United Nations, *United Nations Conference on the Law of Treaties, First and second sessions, Official Records, Documents of the Conference* (hereinafter cited as *Official Records, Documents of the Conference*), p. 136.

- (127) United Nations, *United Nations Conference on the Law of Treaties, First session 1968, Official Records, Summary records of the Plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole* (hereinafter cited as *Official Records, Summary records*), 21st meeting, p. 108, para. 11.

- (128) 実際、スイス政府もアメリカ修正案と同一の箇所に「当該留保が一六条(a)及び(b)項により禁止されていない場合には」という文言の挿入を提案し、対応関係の明確化を求め了った。*Official Records, Documents of the Conference, supra note* 126.

- (129) Tsunoka (Japan), *Official Records, Summary records, supra note* 127, p. 110, para. 29, Sinclair (United Kingdom), *ibid.*, p. 114, para. 74, Blix (Sweden), *ibid.*, 22st meeting, p. 117, paras. 28-29, 32-33, Adamsen (Denmark), *ibid.*, 23st meeting, p. 121, para. 8, Hayes (Ireland), *ibid.*, pp. 122-123, paras. 18-20, Jagota (India), *ibid.*, 24st meeting, p. 128, para. 28, Krishnadasan (Zambia), *ibid.*, p. 129, para. 41.

- (130) Waldock, *ibid.*, 24st meeting, p. 126, para. 7.

- (131) この点は、カナダ代表との質疑におうて、異議の理由は非両立性に限定されなうといふことが、国際法委員会の意向で

条約法条約における留保の「有効性」の決定について

あったと、ウォルドックにより確認されている。Waldock, *ibid.*, 25st meeting, p. 133, paras. 3. カナダ代表の質問について
¹³² Wershof (Canada), *ibid.*, 24st meeting, pp. 132-133, para. 77.

(132) See, e.g. Redgwell, *supra* note. 1, pp. 404-408.

(133) もともと、しほしほ指摘されるように、条約法条約の規定では、留保が条約の特定の規定の適用を排除する内容のものである場合には、当該留保の「受諾」とそれに対する「異議」という全く異なる法律行為が、実質的には同一の帰結を生ずることになってしまう。この点については、寺澤一・山本章二・広部和也編『標準国際法』（青林書院、一九九〇年）、三六四—三六六頁（河西直也執筆担当部分）、Massimo Coccia, “Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights,” *California Western International Law Journal*, Vol. 15, 1985, p. 36, Ruda, *supra* note. 32, pp. 196-200, Belinda Clark, *supra* note. 39, pp. 307-310. Sinclair, *supra* note. 40, pp. 76-77. ¹³⁴を参照。

(未完)